



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 004-2024

CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO
(Demandante)

vs.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN
(Demandada)

LAUDO ARBITRAL

Arbitro Único
Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza

Secretaria Arbitral
Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 21 de enero del 2025

RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 09-2024/AU/HITS

Huánuco, 21 de enero del 2025

VISTOS: El expediente Arbitral; en la ciudad de Huánuco, en la presente fecha, el Tribunal Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la LCE, RLCE, la LEY DE ARBITRAJE y las normas establecidas por las PARTES, valorando las pruebas ofrecidas y actuadas en este arbitraje, revisando los argumentos y deliberado en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, contestación de demanda, con respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las partes, dicta el presente Laudo Arbitral de Derecho.

1. DATOS GENERALES Y ABREVIATURAS

1.1. DATOS GENERALES:

Demandante	: CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO
Demandada	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN
Contrato	: Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC
Servicio	: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO".
Proceso de Selección	: Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC
Monto del contrato	: S/ 1,687,868.00 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 00/100 Soles)
Fecha de la convocatoria	: 24 de julio de 2018
Fecha de firma del contrato	: 18 de diciembre de 2018
Inicio del arbitraje	: 24 de enero de 2024

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIEL LÓPEZ ECHAVARRÍA TAFUR
SECRETARÍA ARBITRAL

Tipo de arbitraje : Institucional, Nacional y de Derecho

Materia de las controversias :

- Nulidad de contrato
- Pago de Entregables
- Devolución de Garantías
- Condena de costas y costos arbitrales.

1.2. ABREVIATURAS:

ACTA DE INSTALACIÓN

: Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 18 de marzo del 2024.

COD

: Cuaderno de Obra Digital.

EL CENTRO

: Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

EL CONTRATO

: Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito para la Ejecución del servicio "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO".

EL CONTRATISTA
EL DEMANDANTE
EL CONSORCIO
(indistintamente)

: Consorcio GD Group Saneamiento

EL SERVICIO

: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO".

LA ENTIDAD

: Municipalidad Distrital Constitución

LA DEMANDADA
LA MUNICIPALIDAD
(indistintamente)

LAS PARTES

: Conjuntamente el demandante y demandado

LCE

: Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"
modificada con Decreto Legislativo N° 1341.

LEY DE ARBITRAJE

: Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

LPAG

: Ley del Procedimiento Administrativo General N°
27444.

OSCE

: Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado.

**PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN**

: Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC, correspondiente
para la Ejecución del Servicio "CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES
CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO
ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN –
OXAPAMPA – PASCO".

REGLAMENTO

: Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional "Corporación Imperium".

RLCE

: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF
modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

RLPAG

: Reglamento de la Ley del Procedimiento
Administrativo General N° 27444.

TUO de la LPAG

: Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General N° 27444.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

2.1. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

Según lo dispuesto en el ACTA DE INSTALACIÓN, las PARTES establecieron como sede del arbitraje la ciudad de Huánuco y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO ubicado en el jirón 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, de esta localidad de Huánuco Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. Sin perjuicio de ello, las actuaciones arbitrales podrán realizarse fuera de esta sede, o de manera remota a través de la plataforma virtual (correo: imperium.sg.2021@gmail.com). Todas las decisiones, resoluciones y comunicaciones del Árbitro Único se entienden emitidas en la sede del arbitraje, sin perjuicio del lugar físico donde se encuentren sus miembros o del lugar donde sean firmados los instrumentos que las contienen.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Parte Demandante:

Razón Social
Representante
Domicilio (s)

: CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO
: Sr. Juan Carlos García Durand
: Pje. Santa Rosa N° 184 del distrito, provincia y departamento de Huánuco
: jcarlos.garciad12@hotmail.com y
: ecosac.abogados@gmail.com

Parte Demandada:

Razón Social
RUC
Procurador Público
Domicilio (s)

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONSTITUCIÓN
: 20207763820
: Abg. Carmen Elizabeth Cortez Román
: Av. Fernando Belaunde Terry S/N – IV Etapa, distrito de Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco
: carmencortez2226@hotmail.com y
: carelicortezroman@gmail.com

2.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Producto del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, devenida del Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC, se dispuso la ejecución del servicio: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO".

2.4. EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL:

El presente arbitraje se inicia en amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, que dice:

"... Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución el contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por arbitro único o tribunal arbitral, el cual la ENTIDAD propondrá de darse el caso al cual la empresa deberá acogerse.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del estado..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

2.5. COMPETENCIA ARBITRAL:

Conforme indica la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018 y estando al acuerdo de las PARTES, se estableció la competencia del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium" y su reglamento para conocer la presente causa, por lo que en aplicación del artículo 11° del D.L. 1071, atendiendo también a lo indicado por el numeral 184.1, 184.4 del artículo 184° e inciso b) numeral 185.4 del artículo 185° del RLCE, así como por el Principio de Autonomía de la Voluntad o Voluntariedad, las partes han tomado la decisión de sustraerse del sistema de justicia tradicional para someter la solución de sus conflictos a la justicia arbitral, con plena libertad para elegir a los árbitros, reglas del proceso, lugar y ley aplicable de ser el caso.

2.6. TIPO DE ARBITRAJE:

El arbitraje es Institucional, Nacional y de Derecho conforme a lo dispuesto por el Convenio Arbitral, la LCE y el RLCE.

2.7. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL:

De conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 26 del REGLAMENTO, las PARTES dejaron a consideración de la Directora del CENTRO a fin de designar al Árbitro Único que conocería la presente controversia; siendo nombrada como Árbitro Único a la abogada

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza, quien luego de su designación, declaración de Independencia, Imparcialidad, disponibilidad y comunicando de manera formal su aceptación al cargo, mediante el ACTA DE INSTALACIÓN se fijaron las reglas definitivas del proceso arbitral y se declaró que el Tribunal Arbitral en calidad de Arbitro Único se encontraba válidamente constituido. Además, la designación del Árbitro Único se efectuó de acuerdo con las reglas establecidas por las PARTES y el REGLAMENTO, quienes manifestaron su conformidad con el procedimiento de designación, no habiéndose planteado objeción o recusación alguna durante el proceso arbitral.

2.8. MARCO LEGAL APLICABLE AL ARBITRAJE:

- 
- 2.8.1. De acuerdo con lo señalado en el ACTA DE INSTALACIÓN, la Ley aplicable al fondo de la controversia en el presente proceso será la Ley peruana.
- 2.8.2. Sin perjuicio de lo señalado, resulta conveniente precisar que, con respecto a las normas procesales aplicables al presente arbitraje, será de aplicación el REGLAMENTO y la LEY DE ARBITRAJE.
- 2.8.3. En cuanto al fondo de la controversia, ésta se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes a la fecha de convocatoria del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, tal como menciona el OSCE a través de la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que "Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción... (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

Ello en concordancia con lo señalado por la Opinión N° 057-2019-DTN, en el cual se establece:

"Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo. (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 2.8.4. Consecuentemente, la ley aplicable al fondo de la controversia es la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" modificada con Decreto Legislativo N° 1341 y

su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF; de igual manera, también se aplicará la jurisprudencia en la materia emitida por el OSCE.

- 2.8.5. A su vez, y estando a lo dispuesto en la cláusula Décimo Octava del CONTRATO, solo en lo no previsto en este contrato, la LCE y el RLCE, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

2.9. **DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES:**

- 2.9.1. El demandante presentó su Demanda Arbitral dentro del plazo otorgado. La demandada fue debidamente emplazada con dicha demanda, la misma que fue contestada.
- 2.9.2. Las partes, durante el proceso arbitral, ofrecieron medios probatorios que fueron incorporados por la Árbitro Único para tener mayores elementos para resolver, así como se tiene medios probatorios de oficio requeridos por el Tribunal Arbitral.
- 2.9.3. Las partes tuvieron plena libertad para ofrecer y actuar todos los medios probatorios que consideraran pertinentes, sin limitación alguna, así como para expresar sus posiciones de hecho y de derecho, habiendo tenido amplia oportunidad de presentar sus alegatos escritos y de informar oralmente, con la participación de sus abogados, respetando en todo momento su irrestricto ejercicio del derecho de defensa, en igualdad de condiciones, en resguardo del debido proceso.

2.10. **SOBRE LOS GASTOS ARBITRALES:**

- 2.10.1. Mediante las reglas fijadas por las PARTES en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/14,119.00 (CATORCE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 SOLES), la misma que debía ser cancelada en forma equitativa por las partes, a razón de S/ 7,059.00 (SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES) por cada una, no estando incluido en este monto lo establecido en el segundo párrafo del numeral 22 de la referida Acta, ni los costos que irroguen de producirse medios probatorios de oficio, indicados en el numeral 33 de la misma.
- 2.10.2. Asimismo, se estableció que en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos, ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a

fin de que la Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

- 2.10.3. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Árbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

- 2.10.4. Así también, se debe dejar constancia que las PARTES asumieron en partes iguales el costo total del presente proceso arbitral, tal como se encontraba ordenado.

DEL LAUDO:

- 2.11.1. El presente laudo es emitido dentro del plazo establecido. Se considera necesario resaltar que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, así como producir certeza en el juzgador respecto a las pretensiones planteadas, de acuerdo a lo consagrado por los principios generales en materia probatoria.

- 2.11.2. De igual forma, la Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

- 2.11.3. Asimismo, se advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.

- 2.11.4. Finalmente, la Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

- 2.11.5. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.

2.12. PLAZO PARA LAUDAR:

Tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones mediante Resolución N° 07-2024/AU/HITS de fecha 28 de noviembre del 2024, plazo que fuera ampliado por 15 días hábiles adicionales mediante Resolución Arbitral N° 08-2024/AU/HITS de fecha 26 de diciembre del 2024.

2.13. CUESTIÓN PREVIA SOBRE LA CORRECCIÓN DE UN ERROR MATERIAL

2.13.1. El arbitraje es una jurisdicción independiente de la jurisdicción común, que se explica no como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustituto, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de sus controversias.

2.13.2. Es así que el árbitro tiene competencia para resolver sobre las materias puestas a su conocimiento, también tiene la obligación de emitir decisiones que respeten el orden jurídico tanto sustantivo como procesal, partiendo de la Constitución y luego bajando a las normas de carácter legal y así sucesivamente, siempre prefiriendo las de mayor rango a las de inferior jerarquía, y siempre, siempre, subordinándose a la Constitución, máxime cuando se trata de derechos que tiene reconocimiento expreso a nivel fundamental.

2.13.3. Conforme a ello, la suscrita advierte la ocurrencia de un error material en el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 21 de octubre del 2024, concretamente de forma errónea se ha consignado como punto controvertido lo siguiente:

- ❖ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no, que el Árbitro Único, DECLARE SIN EFECTO LEGAL la Carta N.º 001- 2024-CONSORCIO GS&Y/PAVV-RC, Informe Técnico de Supervisión de Obra N° 16 y la Valorización de Obra N° 16, correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2023, con las que la supervisión de obra elaboró, presentó y aprobó la Valorización N.º 16, a razón del incumplimiento de contratista en la presentación de la Valorización correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido por el numeral 194.6 del artículo 194 del RLCE.

2.13.4. Sin embargo, de la escucha del audio y video de la audiencia, así como de la revisión del texto indicado, se tiene que el número de documentación y demás datos no guardan correspondencia ni tienen relación con el presente proceso arbitral, razón por la cual es evidente que se consignó erróneamente dicho punto controvertido, razón por la cual deberá ser corregido sin más trámite por tratarse de errores materiales; conforme a lo expuesto, **CORRÍJASE** el ítem II del Acta de

Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios de fecha 21 de octubre del 2024, solo en el extremo de **suprimir** el mal llamado cuarto punto controvertido consignado, **corrigiéndose** la numeración de los demás puntos controvertidos como corresponda (entendiéndose que en total son cinco los puntos que versan sobre la presente causa) y **dejándose** incólume en todo lo demás que contiene.

3. PRINCIPALES ANTECEDENTES PROCESALES:

3.1. Con fecha 24 de enero del 2024, el DEMANDANTE presenta al CENTRO la solicitud de arbitraje.

Con fecha 29 de enero del 2024 se emite la Resolución Directoral Nº 006-2024/D(e)GLET/HCO, mediante la que se admite a trámite la solicitud de arbitraje y se corre traslado a la DEMANDADA, quien fuera válidamente notificada en su domicilio legal con fecha 31 de enero del 2024.

3.3. Con fecha 12 de febrero del 2024, la DEMANDADA se apersona al proceso a través de su Procuradora Publica, Dra. Carmen Elizabeth Cortez Román, aceptando la competencia del centro y el tipo de arbitraje, señalando sus domicilios a efectos de las notificaciones procesales.

3.4. Con fecha 21 de febrero del 2024, se lleva a cabo el Acta de Registro Sobre los Actos de Preparación de la Audiencia Especial con la asistencia de ambas PARTES, en la cual se establece la forma de comunicación durante la tramitación del proceso arbitral y ambas acuerdan que sea el CENTRO, mediante su directora, quien designe al árbitro único que conocerá el proceso, con todo lo demás que contiene.

3.5. Con fecha 01 de marzo del 2024, se emite la Resolución Directoral Nº 14-2024/D(e)GLET/HCO mediante la cual, entre otros, se considera la propuesta de la directora encargada del CENTRO sobre la designación de la Abg. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza para que ocupe el cargo de Arbitro Único, se le pone de conocimiento a dicha profesional para su aceptación, se señala fecha para la audiencia de instalación del tribunal arbitral y demás trámites correspondientes.

3.6. Con fecha 18 de marzo del 2024, se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único mediante la cual se fijan las reglas del proceso arbitral, se designa a la Abg. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza como Arbitro Único y se declara por válidamente instalado el Tribunal Arbitral, entre otros.

3.7. Con fecha 10 de abril del 2024, el DEMANDANTE presenta su demanda, adjuntando sus respectivos medios probatorios.

3.8. Con fecha 17 de junio del 2024 el DEMANDADO formula contestación a la demanda arbitral y formula reconvencción.

3.9. Con fecha 03 de octubre del 2024 se emite la Resolución Arbitral N° 06-2024/AU/HITS/HCO, mediante el cual se tiene por ofrecidos los medios probatorios de la contestación de la demanda y se tiene por desestimada la reconvencción planteada por la DEMANDADA, entre otros.

3.10. Con fecha 21 de octubre del 2024, se emite el Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios.

3.11. Con fecha 28 de noviembre del 2024 se emite la Resolución N° 07-2024/AU/HITS, mediante la cual se señala el plazo de 15 días hábiles para emitir el laudo arbitral.

3.12. Con fecha 26 de diciembre del 2024 se emite la Resolución Arbitral N° 08-2024/AU/HITS, mediante el cual se amplía el plazo para laudar por 15 días hábiles adicionales.

4. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Mediante "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 21 de octubre del 2024, se fijaron los siguientes puntos controvertidos:

- ✓ **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A su fecha 04 de diciembre de 2023 y la Carta N° 090-2023-MDC/ALC, mediante las cuales la Municipalidad Distrital Constitución declara la nulidad de oficio del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, por vulnerar las normas y el orden público.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución la entrega a favor del demandante del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del contrato; DECLARANDO y RECONOCIENDO que el contratista ha cumplido con ejecutar al 100% la prestación y/u obligaciones a su cargo contenidas en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC y la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM mediante la que se aprueba la modificación de las Características Técnicas y/o Condiciones Originales (Prestaciones Adicionales) del proyecto, cuyo Expediente Técnico fuera aprobado mediante Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM de fecha 22 de diciembre de 2020, eximiendo al contratista de cualquier otra responsabilidad no prevista en los documentos antes indicados.

- ✓ **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución que realice el pago a favor del demandante de la suma de S/ 337,573.60 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 SOLES) correspondiente al último pago (sexto entregable) del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, modificado con Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM; así como también SE LE ORDENE el pago de los INTERESES LEGALES generados por la suma de S/ 27,011.23 (VEINTISIETE MIL ONCE CON 23/100 SOLES).

- ✓ **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución la devolución y/o pago a favor del demandante de la suma de S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Clausula Séptima del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

5. MEDIOS PROBATORIOS:

De conformidad con el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" de fecha 21 de octubre del 2024, se considerará los siguientes medios probatorios admitidos:

Medios probatorios de la DEMANDA

- 1) Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC
- 2) Carta N° 090-2023-MDC/ALC
- 3) Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A
- 4) Oficio N° 559-2023-MDU/ALC
- 5) Informe N° 0208-2023-MDU/GM
- 6) Informe N° 128-2023-RARB/GAF/MDU
- 7) Informe N° 463-2023/OSG/MDU
- 8) Informe N° 121-2023-RARB/GAFMDU
- 9) Informe N° 080-2023-MDU-OGAJ
- 10) Oficio N° 299-2023-GM/MDC
- 11) Anexo N° 6-Declaración Jurada de Personal Clave Propuesto (AS N°004-2017-MDU/CS)
- 12) Anexo N° 13- Carta de Compromiso de Personal Clave (CP N° 001-2018-CS/MDC)
- 13) Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM
- 14) Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM
- 15) Carta N° 003-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO

Medios probatorios de la CONTESTACIÓN.

- 1.- INFORME N° 959-2023-GM/MDC
- 2.- INFORME LEGAL N° 063-2023-RKGA/EL
- 3.- INFORME N° 1277-2024-GAF-MDC/PPYL (Gerencia de Administración y Finanzas).
- 4.- INFORME N° 836-2023-SGL-GAF/MDC (Sub Gerencia de Logística
- 5.- Memorándum N° 468-2023-GM/MDC (Gerencia Municipal)
- 6.- Carta Notarial, DIRIGIDA AL Sr. Juan Carlos GARCIA DURAN, de fecha 06 de Noviembre del 2023.
- 7.- INFORME N° 51-2023-RKGA/EL (Especialista Legal)
- 8.- INFORME N° 921-2023-GIDUR-MDC (Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural)
- 9.- INFORME N° 197-2023-SGOLYMP-GIDUR/MDC
- 10.- INFORME N° 005-2023/MIZN-CO, del Estado Situacional del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLA ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO, I, II, III, IV, y, V, DISTRITO DE CONSTITUCION-OXAPAMPA-PASCO*.
- 11.- INFORME N° 1020-2024-OGA-MDC/CCF
- 12.- INFORME N° 605-2024-GDT/MDC

6. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único declare NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A su fecha 04 de diciembre de 2023 y la Carta N° 090-2023-MDC/ALC, mediante las cuales la Municipalidad Distrital Constitución declara la nulidad de oficio del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, por vulnerar las normas y el orden público.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

- 6.1. El CONSORCIO señala que la declaración de nulidad del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, realizada mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A, deviene en un acto nulo e invalido que transgrede los principios de la debida motivación y legalidad, ya que el acto administrativo adolece de vicios, tales como:

- La Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A fue emitida pese a que la facultad de la entidad para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo había prescrito.
- La Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A contiene Motivación Aparente que trata de justificar la nulidad del contrato, basándose en hechos y pruebas no ocurridos y/o no aportados.

- 6.2. El CONSORCIO señala además que, la nulidad del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC efectuado por la Municipalidad Distrital Constitución mediante Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A y Carta N° 090-2023-MDC/ALC, deviene en un acto nulo e ineficaz al no contener los requisitos mínimos exigidos por el artículo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, correspondiendo en este caso amparar en su totalidad nuestra pretensión.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

La MUNICIPALIDAD señala que la actuación posterior del CONSORCIO en la ejecución de la obra, estaba viciada ya que no actuó de buena fe, presentando documentación falsa, transgrediendo la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley N° 27444.

- 6.4. La MUNICIPALIDAD señala también que, se le imputa al CONSORCIO, en el procedimiento de selección, documentación falsa, por lo que, aplicando el Principio de Control Posterior, dirigiendo carta notarial al representante comun del CONSORCIO de fecha 06 de noviembre del 2023, hasta la fecha no ha sido contestada, evidenciando que el CONTRATISTA ha incurrido en falsedad, conforme se acreditara en del decurso del proceso arbitral.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

Consideraciones Previas: Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento

- 6.5. Previamente debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.
- 6.6. Por su parte, la propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido, incluyendo sus procedimientos y plazos, sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

"... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

Dicho carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE, que en su Artículo 2º señala:

"... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.

2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.7. Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como la ENTIDAD y el CONTRATISTA, el respeto irrestricto a los procedimientos y demás instituciones establecidas por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Ampliación de Plazo, Penalidades, Resolución de Contrato, etc.

Consideraciones Previas: Sobre el Contrato Administrativo

- 6.8. Resulta importante entender el origen de lo que se conoce como contrato administrativo, para lo cual citaremos a GASPAR ARIÑO ORTIZ¹, quien nos dice que, en un Estado de Derecho, el Estado tiene dos formas de ejercer sus funciones, la primera mediante actos y procedimientos unilaterales cabe resaltar que en dicho primer supuesto actúa como poder y ejerce su autoridad, es decir estamos ante el *Ius Imperium*. Sin embargo, en otros momentos **el Estado requiere contar con el concurso de iniciativas privadas y para ello recurre a un instrumento creado en el seno del Derecho Civil: el contrato**, el cual vendría a ser la segunda forma en la que la administración pública busca ejecutar sus funciones.

- 6.9. Ahora bien, analizando lo que significa el contrato desde un punto de vista netamente civilista, podremos definirla como el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, siendo que en el ámbito civil la voluntad de las partes tiene una esencial importancia para definir lo que vendría a ser el

¹ ARIÑO ORTIZ; Gaspar. El Enigma del Contrato Administrativo (2007). Pág. 86 – 87.

esquema contractual, estableciéndose que el contrato es una relación horizontal entre las personas que integran el pacto. Lo que en otros términos se definiría que para el Derecho Civil los contratantes son iguales.

6.10. Para el caso de los contratos administrativos, no podemos considerar al contrato administrativo como un contrato eminentemente civil, donde existe una relación horizontal y como consecuencia lógica las comunicaciones que efectúe la administración pública son meras comunicaciones o actos de gestión, puesto que la administración pública actuaría como un ente privado²; dejando de lado aspectos intrínsecos de Derecho Público que son inherentes a todo contrato administrativo.

6.11. Al respecto, DANÓS ORDÓÑEZ³ nos dice que, dentro de un contrato administrativo existe un elemento que le da una naturaleza distinta a la de un contrato civil y la **denomina prerrogativa**; definiéndola como el poder unilateral atribuido a la Administración dentro de una relación contractual que le permite tener una posición prevalente.

6.12. Atendiendo a ello, las actuaciones que efectúe el Estado son considerados como actos administrativos, consecuentemente, sujetos y regulados por la LPAG y la LCE, sin que ello implique el desconocimiento del orden de prelación previsto en el numeral 45.10 del artículo 45° de la LCE, debiendo cumplir los requisitos exigidos en los citados dispositivos, correspondiendo realizar el análisis del caso exigiendo el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3° de la LPAG; mención especial amerita en lo referente al debido procedimiento, respecto a lo cual el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado en numerosas oportunidades estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, tal como la STC Nº 04289-2004-AA que dice:

“... 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal...” (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

² GARCÍA TREVIJANO; José Antonio. Los Actos Administrativos. Civitas. Madrid, 1986. Pág. 43.

³ DANÓS ORDÓÑEZ; Jorge. El Régimen de los Contratos Estatales En El Perú. En Derecho Administrativo Contemporáneo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2007. Pág. 94.

Análisis del presente caso:

6.13. La pretensión demandada tiene que ver con la nulidad del contrato, respecto a lo cual TORRES VÁSQUEZ⁴ nos dice que la nulidad es la sanción impuesta por el derecho a los contratos que infringen sus preceptos; así también, dicho jurista vincula la nulidad a la ineficacia del contrato, la cual puede deberse a factores estructurales o intrínsecos a su proceso de formación o a motivos extrínsecos a ese proceso. En el primer caso estamos ante a la denominada ineficacia estructural (llamada también ineficacia por invalidez o ineficacia originaria), y en el segundo nos encontramos ante la ineficacia funcional (llamada también ineficacia por causa extrínseca o ineficacia sobreviniente).

6.14. La LCE en su artículo 44°, numeral 44.2, regula la figura de la nulidad y sus causales indicando:

"... Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo.

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa.

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato.

f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o

⁴ TORRES VÁSQUEZ, Anibal. Teoría General de los Contratos: Homenaje al profesor doctor Ricardo Luis Lorenzetti / Carlos A. Soto Coaguila; coordinado por Carlos A. Soto Coaguila. 1era. Edición. La Ley. Argentina. 2012. Pág. 1445-1449

recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dativa o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

De igual manera, el numeral 44.4 del artículo 44° del mismo cuerpo normativo, prescribe:

"... 44.4 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.5. EL RLCE, en su artículo 122°, describe el procedimiento a seguir en caso la entidad decida la nulidad de oficio del contrato, señalando:

"... Artículo 122.- Nulidad del Contrato

122.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el artículo 44 de la Ley, debe **cursar carta notarial** al contratista **adjuntando copia fedateada** del documento que declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje.

122.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el artículo 138.

122.3. La acreditación a la que hace referencia el literal f) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley se efectúa mediante sentencia judicial consentida o ejecutoriada o cuando se hubiera admitido y/o reconocido expresamente cualquiera de las circunstancias referidas en dicho literal..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.16. Ahora, en el marco de las pretensiones materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la nulidad del contrato sea válida. En este análisis, esta Árbiter Único evaluará las posiciones vertidas por ambas PARTES, por un lado, la del CONSORCIO que señala que no incurrió en la causal de nulidad invocada por su contraparte; y el de la

MUNICIPALIDAD, que considera que la declaratoria de nulidad del contrato si cumple con los requisitos preestablecidos.

6.17. En la medida que lo pretendido por el CONSORCIO es que se declare sin efecto la nulidad del CONTRATO ejercitada por la MUNICIPALIDAD a través de la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A su fecha 04 de diciembre de 2023, mediante comunicación con Carta N° 090-2023-MDC/ALC; por otro lado, es la posición de la MUNICIPALIDAD que se declare la validez de la nulidad del CONTRATO, por haberse efectuado conforme dispone la ley. De manera que la Árbitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si efectivamente la nulidad ejercitada por la MUNICIPALIDAD ha cumplido con la formalidad que exige la normativa del caso.

6.18. Efectuando la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A, se tiene que la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de declarar la NULIDAD de OFICIO del CONTRATO, invocando la transgresión del Principio de Presunción de Veracidad establecido en el artículo 44° del RLCE, tal como se muestra de los siguientes documentos que sustentan su decisión:

❖ Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, LA NULIDAD DE OFICIO del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 048-2018-GM-MDC, suscrito con el CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, derivado del CONCURSO PÚBLICO N° 01-2018-CS/MDC - Primera Convocatoria; para la Contratación del: "Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de los Sectores Cartagena, Bellas Artes, Juan Velasco Alvarado I, II, III, IV y V, Distrito Constitución, Oxapampa, Pasco"; por transgredir el principio de presunción de veracidad, conforme lo establece el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que se presentó documentación falsa en su propuesta técnica; y demás argumentos expuestos en la presente resolución.

❖ Informe Legal N° 063-2023-RKGA/EL de fecha 29 de noviembre del 2023, adjuntada en la contestación de la demanda, que señala:

↓ Que, de conformidad a lo expuesto en el presente informe legal e informes descritos, es **PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO** del CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N° 048-2018-GM-MDC, suscrito con el CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, derivado del CONCURSO PÚBLICO N° 01-2018-CS/MDC - Primera Convocatoria para la Contratación del: "Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de los Sectores Cartagena, Bellas Artes, Juan Velasco Alvarado I, II, III, IV y V, Distrito Constitución, Oxapampa, Pasco"; por transgredir el principio de presunción de veracidad, conforme lo establece el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que se presentó documentación falsa en su propuesta técnica.

- ❖ Memorando N° 468-2023-GM/MDC de fecha 17 de noviembre del 2023, adjuntada en la contestación de la demanda, que señala:

3. Que, mediante carta notarial, debidamente notificada con fecha 8-11-2023; se requirió al contratista – Consorcio GROUP SANEAMIENTO; para que realice los descargos respecto a lo señalado en el Oficio Nro., 529-2023-MDU/ALC; en vista que ya pasaron los 5 días que tenía para hacer los descargos, conforme a ley.
4. En ese sentido; ORDENO, remita el Informe Técnico respecto al proceso de nulidad del contrato de servicio de consultoría N° 048-2018-GM-MDC (elaboración del Expediente Técnico de la Obra "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III Y IV DISTRITO DE CONSTITUCION – OXAPAMPA – PASCO"); iniciado, por la entidad mediante el control posterior del procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO N° 001-2018/CSMDC. Teniendo como fuente la vulneración de la presunción de la veracidad por parte del consultor (contratista), acreditado con el Oficio N° 0559-2023-MDU/ALC.

- 6.19. Se tiene entonces que la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de declarar la nulidad del contrato, en base a la causal indicada por el inciso b), numeral 44.2 del artículo 44° de la LCE que dice:

"... b) Cuando se **verifique** la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, **previo descargo...**" (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.20. Conforme a ello, la norma ha establecido como **requisitos de validez de la nulidad del contrato**, en base al inciso b), numeral 44.2 del artículo 44° de la LCE, concordante con el numeral 122.1 del artículo 122° del RLCE, que esta se realice conforme a los siguientes presupuestos:

- a) Que la MUNICIPALIDAD verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad.
- b) Que nulidad se ejercite previo descargo del CONTRATISTA.
- c) Que se curse carta notarial al CONTRATISTA adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad.

- 6.21. A continuación, el Arbitro Único procede a verificar el cumplimiento de tales requisitos, conforme a los medios probatorios ofrecidos por las PARTES:

Sobre el primer requisito:

- 6.21.1. El Principio de Presunción de Veracidad se encuentra descrito en el literal 1.7, numeral 1, del artículo IV de la LPAG, por el cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

6.21.2. Ahora bien, el numeral 2.1 de la Opinión N° 093-2019/DTN, hace un interesante análisis sobre lo que implica "verificar" la transgresión al Principio de Presunción de Veracidad, de la siguiente manera:

"... No obstante, la presunción de veracidad no tenía un carácter absoluto, dado que la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obligaba a la administración pública a apartarse de la referida presunción.

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozaban de la presunción de veracidad, por lo que se presumía la certeza de su contenido, salvo que existiera prueba en contrario.

En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la anterior normativa de contrataciones del Estado estaba consagrado el principio de presunción de veracidad, y sólo si existía prueba de que la información contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas no correspondía a la verdad de los hechos, se desvirtuaba tal presunción - estableciéndose las responsabilidades correspondientes en las distintas etapas del proceso de selección-, entendiéndose que dicha prueba debía ser un elemento objetivo, verificable y que causara convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente se hubiese afirmado respecto de los documentos aportados por los administrados..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.21.3. Ello concuerda con lo indicado por la Opinión N° 122-2015/DTN, en el sentido que el Titular de la Entidad tiene la potestad para declarar de oficio la nulidad de un contrato, bajo la causal de transgresión del Principio de Presunción de Veracidad, limitándose a estos dos supuestos: (i) la presentación de documentación falsa o inexacta durante el proceso de selección, como parte de la propuesta técnica; y (ii) la presentación de **documentación falsa o inexacta** para la suscripción del contrato. Además, en reiterada jurisprudencia⁵, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha precisado que la falsedad o inexactitud de un documento se verifica de la siguiente manera:

⁵ Tal como: Resolución N° 2877-2023-TCE-S3, Resolución N° 01614-2024-TCE-S3, Resolución N° 0599-2021-TCE-S4, etc.

- Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.
- Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018.

6.21.4. Entonces, remitiéndonos al presente caso, la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A **no detalla y/o precisa de manera exacta cual es el documento falso o inexacto** que presentó el CONTRATISTA; sin embargo, de la revisión de la **Carta Notarial S/N de fecha 31 de octubre del 2023**, notificada el 07 de noviembre del 2023 (ofrecido en el escrito de contestación), se tiene que la MUNICIPALIDAD requiere al CONTRATISTA que, en el plazo de 05 días, realice el descargo sobre lo expuesto en el Oficio N° 529-2023/MDU/ALC remitido por la Municipalidad Distrital de Umari:

Se le cursa una carta notarial al representante legal del CONSORCIO GROUP SANEAMIENTO, a efecto de realizar su descargo respecto, a lo expuesto en el OFICIO N° 529-2023-MDU/ALC, Acto a realizar en cumplimiento y aplicación supletoria de lo previsto en el Art. 213.2 del D.S. 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27444; en ese sentido, se le concede un plazo de cinco (5) días para hacer el descargo correspondiente conforme a ley



Firmado digitalmente por:
Atalaya BORDENAS ZULLY
BERIZA FIR 04329433 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/11/2023 10:59:29 0500



6.21.5. Ahora, de la revisión de los medios probatorios aportados por las partes, en ninguno de ellos se advierte un Oficio N° 529-2023/MDU/ALC, empero, lo que si obra en autos es el Oficio N° 559-2023/MDU/ALC de fecha 13 de setiembre del

2023 (ofrecido con la demanda), en la que se indica expresamente que el Sr. Juan Carlos García Durand: "... no participó en nuestra entidad en alguna consultoría de obras, ejecutor de obra o consultor proyectista, tampoco registra orden de servicio, contrato de consultoría, ni se registra ningún pago. Respecto si es que trabajó como personal clave o personal no clave, sería pertinente que la Municipalidad Distrital de Constitución, nos precise con exactitud la fecha o el proyecto de inversión, para poder buscar e informar conforme a lo que solicitan..."

Así también, dicho Oficio N° 559-2023/MDU/ALC tiene su sustento en el Informe N° 0208-2023-MDU/GM de fecha 07 de setiembre del 2023 (ofrecido en la demanda), emitido por el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Umari, en la que se indica:

Es un honor de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez remito el Informe de la referencia de la Oficina General de Administración y Finanzas, con respecto a la siguiente información:

- Declaraciones Juradas de todo el personal clave propuesto por el consultor Consorcio Group Huanin.
- Cartas de compromiso del personal Clave del consultor consorcio Group Huanin.

Por otra parte, respecto al pedido de información del Sr. Juan Carlos García Duran, si participo en nuestra entidad en alguna consultoría de obras, ejecutor de obra o consultor proyectista, ya sea como representante o como personal clave o personal no clave, en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre del 2018 al 22 de 2020. Al respecto de lo requerido en el párrafo anterior, por el momento podemos mencionar que el Sr. Juan Carlos García Duran, no participo en nuestra entidad en alguna consultoría de obras, ejecutor de obra o consultor proyectista, tampoco se registra orden de servicio, contrato de consultoría, ni se registra ningún pago. Respecto si es que trabajo como personal clave o personal no clave, sería pertinente que la Municipalidad Distrital de Constitución, nos precise con exactitud la fecha o el proyecto de inversión, para poder buscar e informar conforme a lo que solicitan.

Por lo que se recomienda derivar a la Municipalidad Distrital de Constitución, en atención a su pedido.

- 6.21.7. Conforme a ello, la MUNICIPALIDAD efectuó la fiscalización posterior respecto a los documentos que sustentan la experiencia del personal clave propuesto para el Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC, siendo que en lo referente al Jefe y/o Director de Proyecto, cargo que recaía en el Ing. Juan Carlos García Durand, se hizo el cruce de información sobre un documento aparentemente emitido por el Consorcio Group Huanin con RUC N° 20602692095, en referencia a la consultoría para la elaboración del expediente técnico denominado "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE RASHU Y HUANIN, DISTRITO DE UMARI- PACHITEA- HUÁNUCO" (Adjudicación

Simplificada N° 004-2017-MDU/CS), ejecutada a favor de la Municipalidad Distrital de Umari.

6.21.8.

Sin embargo, de los argumentos de la contestación de la demanda, informes orales, alegatos escritos y de los medios probatorios aportados por las partes, **en ninguno de ellos se indica expresamente cual es el documento falso o inexacto** referido al Ing. Juan Carlos García Durand y por el que se decidiera declarar la nulidad del CONTRATO, ya que, por el Principio de la Carga de la Prueba, quien afirma algo está en el deber de probarlo; es por tal motivo que la suscrita no puede identificar y analizar objetivamente cual es el documento originariamente cuestionado, ya que todo Tribunal Arbitral debe basar su decisión en los medios probatorios y argumentos que las partes hayan aportado durante el proceso; sumado a ello, debemos de tener en cuenta que, contrariamente a lo actuado por la ENTIDAD, el CONTRATISTA si ofreció en su demanda el Anexo N° 13- Carta de Compromiso de Personal Clave, presentada para fines del Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC, con la cual se ofrecía la experiencia del Personal Clave-Jefe y/o Director de Proyecto, al Ing. Juan Carlos García Durand de la siguiente manera:

B. Experiencia

N°	CLIENTE O EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACION	TIEMPO
01	SEDA HUANUCO	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LIQUIDACIONES TECNICAS DE CONVENIO CON SEDA HUANUCO S.A INSPECCION Y RESIDENCIA EN LOS CONVENIOS DE TENDIDO DE REDES DE CAYHUAYNA BAJA	12-Jun-03	11-Sep-03	92 00
02	CHEMONICS INTERNACIONAL INC	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EN SANEAMIENTO	25-May-06	22-Feb-07	274 00
03	CONSORCIO GD GROUP INGENIERIA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VILLA DE CHAGLLA, LOS CASERIOS DE PALTA CRUZ, CEBADA LOMA, COCHACALLA, HUANCAYO Y LOS	25-ene-18	24-may-18	120 00
		BARRIOS DE HUMILDAD, SAN LUIS, GONGAPALOMA, COCHAPAMPA, HUAYCHO, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO			

6.21.9. Ahora bien, durante el trámite del proceso, la MUNICIPALIDAD no ha formulado tacha o cuestionamiento alguno contra el Anexo N° 13 ofrecido con la demanda, y menos aún ha argumentado y/o probado una supuesta falsedad o idoneidad del indicado Anexo N° 13. Es por tal motivo que la suscrita Árbitro Único concluye que el CONTRATISTA no ofreció ningún documento vinculado al Consorcio Group Huanin o la Municipalidad Distrital de Umari, para sustentar la experiencia del Ing. Juan Carlos García Durand en el marco del Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC.



Heidi Ivonne Torres Santos de Kuleza
ARBITRO ÚNICO

6.21.10. Por todo lo expuesto, para la suscrita queda demostrado que la MUNICIPALIDAD no ha verificado plenamente la transgresión al Principio de Presunción de Veracidad, ya que en autos no se acredita prueba suficiente de que la información contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas, no correspondía a la verdad de los hechos y con el cual se desvirtuara tal presunción, siendo que dicha prueba debía ser un elemento objetivo, verificable y que causara convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente se hubiese afirmado, lo que no ocurre para el presente caso, teniéndose por **NO CUMPLIDO** dicho requisito.

Sobre el segundo requisito:

6.21.11. Sobre el particular debemos tener en cuenta que cuando el inciso b), numeral 44.2 del artículo 44° de la LCE prescribe que la nulidad se ejercita previo descargo del contratista, si bien la norma le otorga dicha prerrogativa a la entidad, empero, condiciona tal facultad al ejercicio previo del derecho de defensa de su contraparte, ya que el Derecho a la Defensa posee un reconocimiento y protección a nivel Constitucional, el cual a su vez implica el derecho de las partes a ser escuchadas por autoridad competente, a ser notificadas de los cargos que se les imputan, a acceder a las pruebas, a disponer del tiempo y los medios para ejercer su defensa, a presentar pruebas y a no ser obligadas a auto incriminarse.

6.21.12. Para el presente caso, mediante Carta Notarial S/N de fecha 31 de octubre del 2023 (ofrecido en el escrito de contestación), el cual fuera notificado el 07 de noviembre del 2023, la MUNICIPALIDAD requiere al CONTRATISTA que en un plazo de 05 días realice el descargo sobre lo expuesto en el Oficio N° 529-2023/MDU/ALC, remitido por la Municipalidad Distrital de Umari, tal como se muestra a continuación:



CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

CERTIFICO; QUE. EL DÍA DE HOY A HORAS 10:00 AM. EL PERSONAL DE LA NOTARIA SE APERSONÓ A LA DIRECCIÓN ANTES INDICADA EN LA CARTA NOTARIAL HABIENDO TOCADO LA PUERTA EN REITERADAS OPORTUNIDADES, NO SALIÓ PERSONA ALGUNA, MOTIVO POR EL CUAL SE DEJÓ EL ORIGINAL DE LA CARTA **BAJO PUERTA**, PRECISÁNDOSE QUE SE TRATA DE UN INMUEBLE MATERIAL NOBLE DE TRES PISOS, DE CERÁMICA COLOR BLANCO, UNA PUERTA DE MADERA, CUATRO VENTANAS DE ALUMINIO DE COLOR NEGRO, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DEJO UN PRE - AVISO DE NOTIFICACIÓN **BAJO PUERTA** EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A HORAS 07:00 PM. PARA MAYOR CONFORMIDAD SE TOMÓ EL NÚMERO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 73896381 DE LO QUE DOY FE. =====DAOM=====

HUANUCO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LUIS DOMINIQUE PALACIOS
ABOGADO
NOTARIO DE HUANUCO - PASCO
Reg. C.N.H.P. N° 033

6.21.13.

Es así que, encontrándose válidamente notificada y ante la falta de pronunciamiento del CONTRATISTA, la MUNICIPALIDAD decide emitir la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A; razón por lo cual se tiene por **CUMPLIDO** dicho requisito.

Sobre el tercer requisito:

6.21.14.

Sobre el particular, conforme se expone en la Opinión N°032-2019/DTN, la normativa de contrataciones del Estado establece que la copia fedateada del documento que declaraba la nulidad del contrato, debe ser notificada -al contratista- a través de una carta notarial, la cual deberá diligenciarse de conformidad con lo dispuesto, entre otras normas que resulten aplicables, en el Decreto Legislativo N° 1049 "Decreto Legislativo del Notariado".

6.21.15.

Para nuestro caso, la nulidad fue notificada al CONTRATISTA mediante Carta N° 090-2023-MDC/ALC, la misma que fue diligenciada vía notario público con fecha 06 de diciembre del 2023, al mismo que se adjuntaron copias de la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A las cuales cuentan con el sello de certificación del mismo notario público, con lo cual se tiene por satisfecho a lo requerido por el numeral 122.1 del artículo 122° del RLCE; por tal motivo, se tiene por **CUMPLIDO** dicho requisito.

6.22.

Entonces, a la luz de la causal invocada para la nulidad del contrato y de la documentación sustentatoria aparejada en autos, se tiene que la MUNICIPALIDAD si bien ha cumplido con el segundo y tercer requisito, sin embargo **no acredita haber cumplido con el primer requisito, esto es, no cumplió con verificar plenamente la transgresión al Principio de Presunción de Veracidad**, a través de prueba objetiva, verificable y que causara convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que se hubiese afirmado respecto

de los documentos aportados, y por ende no se encontraba habilitada para declarar la nulidad del contrato bajo el amparo de lo indicado en el inciso b), numeral 44.2 del artículo 44° de la LCE, concordante con el numeral 122.1 del artículo 122° del RLCE.

6.23. En tal sentido, revisado el cumplimiento formal del procedimiento de nulidad contractual, esta Árbitro Único determina que **no se cumplió con el procedimiento establecido para declarar la nulidad del CONTRATO**, razón por la cual la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A y subsecuentemente de la Carta N° 090-2023-MDC/ALC, adolece de vicio sancionado con nulidad, por cuanto ha sido emitida sin seguir el procedimiento establecido.

6.24. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución la entrega a favor del demandante del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del contrato; DECLARANDO y RECONOCIENDO que el contratista ha cumplido con ejecutar al 100% la prestación y/u obligaciones a su cargo contenidas en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC y la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM mediante la que se aprueba la modificación de las Características Técnicas y/o Condiciones Originales (Prestaciones Adicionales) del proyecto, cuyo Expediente Técnico fuera aprobado mediante Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM de fecha 22 de diciembre de 2020, eximiendo al contratista de cualquier otra responsabilidad no prevista en los documentos antes indicados.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

6.25. Señala que ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contenidas en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC y la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM, razón por la cual mediante Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO".

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.26. Únicamente señala que esta pretencion se demostrará en la estación respectiva, luego de actuadas las pruebas ofrecidas por dicha parte.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.27. La Opinión N° 008-2022/DTN señala:

“... Como se señaló al absolver la consulta anterior, **para dar la conformidad de las prestaciones ejecutadas por el contratista**, en el marco de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, **se requiere que la Entidad realice la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas**, siendo que en el caso de contrataciones perfeccionadas mediante una orden de compra o de servicio, el numeral 168.2 del artículo 168 del Reglamento ha previsto la posibilidad de que luego de la verificación efectuada, la conformidad conste en dicho documento, sin perjuicio de lo señalado, la entidad puede decidir que en estos casos la conformidad conste en un informe del área usuaria...” (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.28. Que, la entrega del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio resulta ser un acto a cargo de la entidad, previa verificación por parte del funcionario responsable del área usuaria de la contratación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, y que para el contratista determina contar con el documento que acredite el cumplimiento de sus prestaciones conforme a las características y condiciones requeridas por la entidad contratante; ahora bien, siguiendo a MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁶, podemos definir a la Conformidad de la Prestación como el acto de control a cargo del área usuaria por la que esta expresa la comprobación favorable de la cantidad y calidad de las prestaciones comprometidas por el contratista- bienes entregados, funcionamiento, rendimiento, medición de la obra, calidad del servicios- previa realización de las pruebas necesarias. La Conformidad de la Prestación produce los siguientes efectos:

- Activa el mecanismo para el proceder al pago al contratista
- Aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones.
- Libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.

- 6.29. De la misma forma MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁷ señalan que los derechos del contratista frente a la entidad contratante son, entre otros:

⁶ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 156.

⁷ Ob. Cit. Pág. 157.

- A percibir el precio pactado o la retribución convenida luego de haber ejecutado su prestación y obtenido la respectiva conformidad, como regla general, y en caso de retrasos, al cobro de intereses legales desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

6.30. Remitiéndonos al presente caso, este tribunal ha determinado que la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A y Carta N° 090-2023-MDC/ALC, adolece de vicio sancionado con la nulidad, por cuanto han sido emitidas sin seguir el procedimiento establecido por el inciso b), numeral 44.2 del artículo 44° de la LCE, concordante con el numeral 122.1 del artículo 122° del RLCE, que faculta a la MUNICIPALIDAD a declarar la nulidad del contrato. En tal sentido este Tribunal Arbitral ha determinado la validez y vigencia del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito para la Ejecución del servicio "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO"; consecuentemente, los efectos contractuales para las PARTES se tienen por restituidos y reconocidos.

6.31. Habiéndose determinado la validez y vigencia del CONTRATO, y teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión, corresponde al Tribunal Arbitral verificar si el CONTRATISTA ha cumplido con todas las obligaciones contractuales pactadas, generando el derecho de obtener el Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a lo establecido por el artículo 143° del RLCE que dice:

"... Artículo 143.- Recepción y conformidad

143.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

143.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

143.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARÍA ARBITRAL

143.4. De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad. Tratándose de consultorías y de contratos bajo modalidad mixta el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

143.5. En el caso de las contrataciones bajo modalidad mixta, una vez subsanadas las observaciones por el contratista, se suscribe el Acta de Recepción de la infraestructura o áreas de terreno entregadas al inicio de la ejecución contractual y, dentro de los sesenta (60) días siguientes, este debe presentar un informe final a la Entidad. El contrato concluye con la conformidad del informe final, la misma que se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

143.6. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.32. En ese sentido, de la norma invocada se entiende que la "recepción" de la prestación es el acto a través del cual se reciben los bienes o servicios o se admite la consultoría o se recibe la obra ejecutada de acuerdo con el expediente técnico de obra, mientras que la "conformidad de la prestación" es el acto a través del cual se otorga la aceptación y la aprobación de la prestación, la misma que ha sido entregada o recibida conforme a los requerimientos exigidos, a las características técnicas y/o requisitos funcionales, a los términos de referencia, conformidad de obra o bajo las condiciones contractuales y normativas aplicables, que tiene como finalidad determinar su conformidad.

6.33. Ahora bien, la "conformidad" no necesariamente deberá de revestir la forma de un informe, sino que dicho acto debe entenderse como cualquier documento que contenga la certificación de la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales debidamente verificada por el área usuaria, tal como señala la Opinión N° 011-2024/DTN que dice:

"... En ese sentido, el procedimiento para efectuar la conformidad se encuentra a cargo del área usuaria de la Entidad, la cual, a efectos de otorgar la conformidad correspondiente, debe realizar la verificación respecto de "la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales", de acuerdo a los documentos que conforman el contrato, para luego emitir el informe de conformidad correspondiente.

Cabe precisar que la normativa menciona la utilización de un "informe" no refiriéndose, necesariamente, a la nomenclatura o denominación del documento a utilizar para emitir la conformidad, sino más bien debido a la función que dicho documento tiene, dado que su finalidad es informar respecto de la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales; adicionalmente, este documento, por lo general, es dirigido o derivado al órgano encargado de las contrataciones para que realice las gestiones posteriores que correspondan respecto de la administración del contrato..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.34. Para nuestro caso, la finalidad del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC es la **elaboración del Expediente Técnico** del proyecto: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO", prestación que debe ser efectuada conforme a los lineamientos y características establecidas por la Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2018-CS/MDC, así como de los documentos que la integran, llámese termino de referencia, entre otros.

- 6.35. Es así que en autos se tiene la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM emitida con fecha 22 de diciembre del 2020, mediante la cual, entre otros, La MUNICIPALIDAD aprueba el Expediente Técnico del proyecto: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO", es decir, que mediante acto administrativo firme la MUNICIPALIDAD ha certificado la calidad, cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales del servicio, recepcionando y otorgando la conformidad de la prestación al 100%, ya que durante el tramite del presente proceso ninguna de las partes ha presentado documento alguno que demuestre que dicha resolución ha sido invalidada o anulada, siendo que para el Tribunal Arbitral la emisión de la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM demuestra inequívocamente que la MUNICIPALIDAD ha otorgado la recepción y conformidad del servicio, conforme establece el artículo 143° del RLCE, tal como se muestra a continuación:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico del proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN -DISTRITO DE CONSTITUCIÓN -OXAPAMPA-PASCO", con Código SNIP 360161, con el monto de S/. 183'123,012.63 (Ciento Ochenta y Tres Millones Ciento Veinte y Tres Mil doce con 63/100 Soles), con un plazo de veinticuatro (24) meses para su ejecución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - RESPONSABILIZAR al Bach/Ing. Jhon Cristhian CARRANZA MIRABAL, Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el cumplimiento de dispuesto, bajo responsabilidad funcional y administrativa.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCÁRGUESE a la Secretaría General la notificación y publicación de la presente Resolución, dentro del término de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

6.36. Ahora, respecto a los argumentos de la MUNICIPALIDAD, si bien en su escrito de contestación ha indicado en forma lacónica que el CONTRATISTA no ha cumplido con ejecutar las prestaciones a su cargo, la suscrita Arbitro Único tiene ha bien analizar el Informe N° 005-2023/MJZN-CO de fecha 07 de agosto del 2023, emitido por el Ing. Moisés J. Zamudio Núñez, el cual contiene el informe del estado situacional del proyecto ordenado por la MUNICIPALIDAD, documento que si bien contiene aseveración del supuesto incumplimiento del CONTRATISTA en la entrega completa del expediente técnico, sin embargo, dicho documento constituye una apreciación de parte, mas no existe en autos el acto administrativo complementario que anule o invalide formalmente la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM (que aprueba el expediente técnico) o la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM (que aprueba las prestaciones adicionales), es decir, la MUNICIPALIDAD alega el incumplimiento de los términos contractuales del CONTRATISTA pero, sin embargo, no acredita haber efectuado las acciones correctivas ante tales vicios, ni mucho menos ha resuelto el CONTRATO ante el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales de su contraparte, teniendo en cuenta que la MUNICIPALIDAD declaró la nulidad del CONTRATO por haber advertido supuestos documentos falsos en su oferta, es decir, anuló el CONTRATO por hechos distintos a un incumplimiento de obligaciones contractuales; así también, resulta importante precisar que pese a estar debidamente emplazada, la MUNICIPALIDAD no ha formulado mayor resistencia procesal o contradicción a la pretensión del CONTRATISTA, únicamente se ha limitado a negar tajante y lacónicamente el escrito de la demanda, pero sin formular mayores argumentos que demuestren de forma razonable el amparo de su contestación, ni mucho menos ha adjuntado los medios probatorios que la sustente, ya que el Árbitro Único no puede suplir a las partes en el ejercicio de su defensa procesal.

6.37. Conforme a ello, resulta evidente para la suscrita que la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM **constituye la recepción y conformidad del Expediente Técnico** del proyecto: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO", acto que se encuentra firme, valido y vigente a la fecha, razon por la cual corresponde que la MUNICIPALIDAD otorgue el Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, ya que dicho documento constituye un derecho del CONTRATISTA por la ejecución de la prestación al 100%, dado que en autos se ha verificado el cumplimiento de la totalidad de los términos contractuales pactados por las PARTES.

6.38. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución que realice el pago a favor del demandante de la suma de S/ 337,573.60 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 SOLES) correspondiente al último pago (sexto entregable) del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, modificado con Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM; así como también SE LE ORDENE el pago de los INTERESES LEGALES generados por la suma de S/ 27,011.23 (VEINTISIETE MIL ONCE CON 23/100 SOLES).

Resumen de la posición del DEMANDANTE

6.39. Señala que, estando el servicio culminado, corresponde que la entidad haga efectivo el pago del monto correspondiente al sexto entregable del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, modificado con Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM, pago requerido previamente con Carta N° 003-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO de fecha 20 de enero de 2023, el mismo que hasta la fecha la entidad se niega en reconocer.

Resumen de la posición de la DEMANDADA

6.40. Señala que la pretensión está sujeta a que se acrediten los extremos solicitados, con la actuación de pruebas que respalden esta pretensión.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

6.41. El presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor del DEMANDANTE, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁸, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

6.42. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista, tal como señala la Opinión N° 116-2016/DTN que dice:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.43. Entonces, tratándose de obligaciones reciprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al CONTRATISTA se ha generado el derecho de recibir

⁸ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d9/content>

la contraprestación convenida por lo realmente ejecutado, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁹:

"... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000). El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.
- La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.
- La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.44. Para el presente caso, este Tribunal Arbitral ha determinado la validez y vigencia del Contrato de Servicio de Consultoría Nº 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito para la Ejecución del servicio "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO"; consecuentemente, los efectos contractuales para las PARTES se tienen por restituidos y reconocidos; también se ha determinado que la Resolución Gerencial Nº 206-2020-MDC/GM constituye la recepción y conformidad del Expediente Técnico del proyecto, tras haber verificado el cumplimiento

⁹ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44.
<https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef6f11d8/content>

de la totalidad de la prestaciones a cargo del CONTRATISTA; entonces, se ha enervado o restaurado nuevamente el derecho del CONTRATISTA en obtener la contraprestación por los servicios efectivamente ejecutados, correspondientes al sexto entregable (prestaciones adicionales) establecido en la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM que señala:

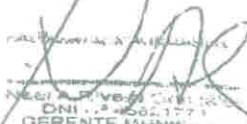
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la CONSULTORÍA EN GENERAL para la EJECUCIÓN en la Modificación de las Características Técnicas y/o Condiciones Originales- Prestaciones Adicionales de la elaboración del Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, DISTRITO DE CONSTITUCIÓN-OXAPAMPA-PASCO", por el monto que asciende a S/. 334,038.53 (Trescientos Treinta y Cuatro mil Treinta y Ocho con 53/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: TIPIFICAR la Presentaciones Adicionales de la elaboración del Proyecto antes mencionado, deberá entregar como fecha límite el 15 de noviembre y el PAGO RESTANTE se realizará a la entrega del Expediente Técnico (SEXTO ENTREGABLE).

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución al CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO y a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural y demás órganos estructurados de la Municipalidad Distrital de Constitución, con las formalidades de caso conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


DNI: 45061771
GERENTE GENERAL

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
GABRIELA LUCERO BELVERDIA TAPIA
SECRETARÍA ARBITRAL

- 6.45. De igual forma, resulta relevante tener en cuenta que durante el trámite del presente proceso ninguna de las partes ha presentado documento alguno que acredite que la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM ha sido invalidada o anulada, siendo que para el Tribunal Arbitral la emisión de la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM demuestra inequívocamente que la MUNICIPALIDAD ha otorgado la recepción y conformidad del servicio, incluyendo las prestaciones adicionales.
- 6.46. Respecto el Informe N° 005-2023/MJZN-CO de fecha 07 de agosto del 2023, emitido por el Ing. Moisés J. Zamudio Núñez, el cual contiene el informe del estado situacional del proyecto ordenado por la MUNICIPALIDAD, documento que si bien contiene aseveración del supuesto incumplimiento del CONTRATISTA en la entrega completa del expediente técnico, sin embargo, dicho documento constituye una apreciación de parte, mas no existe en autos el acto administrativo complementario que anule o invalide formalmente la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM (que aprueba el expediente técnico) o la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM (que aprueba las prestaciones adicionales), es decir, la MUNICIPALIDAD alega el incumplimiento de los términos contractuales del CONTRATISTA pero, sin embargo, no acredita haber efectuado las acciones correctivas

ante tales vicios, ni mucho menos ha resuelto el CONTRATO ante el supuesto incumplimiento de las obligaciones contractuales de su contraparte, teniendo en cuenta que la MUNICIPALIDAD declaró la nulidad del CONTRATO por haber advertido supuestos documentos falsos en su oferta, es decir, anuló el CONTRATO por hechos distintos a un incumplimiento de obligaciones contractuales del CONTRATISTA; así también, resulta importante precisar que pese a estar debidamente emplazada, la MUNICIPALIDAD no ha formulado mayor resistencia procesal o contradicción a la pretensión del CONTRATISTA, únicamente se ha limitado a negar tajante y lacónicamente el escrito de la demanda, pero sin formular mayores argumentos que demuestren de forma razonable el amparo de su contestación, ni mucho menos ha adjuntado los medios probatorios que la sustenten, ya que el Árbitro Único no puede suplir a las partes en el ejercicio de su defensa procesal.

6.47. Conforme a ello, para la suscrita Arbitro Único ha quedado plenamente demostrado que la Resolución Gerencial Nº 206-2020-MDC/GM constituye la recepción y conformidad del Expediente Técnico del proyecto y, por lo tanto, se ha generado el derecho del CONTRATISTA de cobrar el sexto entregable de las prestaciones adicionales establecido en la Resolución Gerencial Nº 0113-2020-MDC/GM, por la suma de S/ 337,573.60 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 SOLES).

6.48. Finalmente, respecto a los **intereses**, el CONTRATISTA solicita que se le reconozca el pago por dicho concepto que se hayan "generado" por la demora en el pago del sexto entregable; para ello será necesario establecer o definir tres aspectos:

- a) El sustento legal que le da derecho al pago de los intereses.
- b) El tipo de interés aplicable.
- c) La forma de cálculo y el monto por tales intereses.

6.49. Sobre el primer y segundo aspecto, el sustento legal que le da al CONTRATISTA el derecho de pago de los intereses se encuentra descrito en los numerales 39.1 y 39.3 del artículo 39º de la LCE que dice:

"... 39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.

(...)

39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora..." (La negra, cursiva y subrayado son nuestros)

Así también, el numeral 149.1 del artículo 149° del RLCE, establece:

"... 149.1. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.50. Bajo tales considerandos se tiene que: i) Mediante el presente laudo arbitral se ha determinado la validez y vigencia del CONTRATO; ii) Con fecha 22 de diciembre del 2020 se emite la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM, con la cual se aprueba el expediente técnico del proyecto; iii) habiendo la MUNICIPALIDAD otorgado la recepción y conformidad del servicio, entonces, se ha originado el derecho del CONTRATISTA del pago de su contraprestación; y iv) La entidad no ha cumplido hasta la fecha con el pago del sexto entregable a favor del contratista; por lo que, aplicando la consecuencia descrita en los numerales 39.1 y 39.3 del artículo 39° de la LCE, concordante con el numeral 149.1 del artículo 149° del RLCE, corresponde reconocer el pago de los intereses a favor del contratista, haciendo mención que dicho precepto legal señala el tipo de interés que deberá abonar la parte que incumple con sus prestaciones, considerando que el contrato no establece un tipo de interés específico, por lo que el mismo será un interés legal.

6.51. Sobre el tercer aspecto, siendo que la pretensión demandada por el contratista está referida a que se le reconozca el pago de los intereses generados, en tal sentido, habiendo la MUNICIPALIDAD otorgado la recepción y conformidad del servicio se ha originado el derecho del CONTRATISTA del pago de su contraprestación, situación que siendo de conocimiento de la entidad, ésta se negó a cumplir con su obligación pese a que según la Clausula Cuarta del CONTRATO, la MUNICIPALIDAD debía realizar el pago dentro de los 15 días calendario de emitida la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM, es decir, el pago se debió efectuar hasta el 06 de enero del 2021, por lo que su incumplimiento acarrea que se hayan generado los intereses legales a partir del día siguiente de la indicada fecha, hasta el momento de la emisión del laudo arbitral.

6.52. En ese sentido, la Arbitro Único a efectos de calcular el monto de los intereses legales generados, ha recurrido a la calculadora del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)¹⁰, estableciendo mediante dicha herramienta que los intereses legales hacen a la suma

¹⁰ Dicha calculadora puede ser verificada en la siguiente dirección electrónica (web): <https://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales.html>

de S/ 34,095.80 (Treinta y Cuatro Mil Noventa y Cinco con 80/100 Soles), tal como se muestra a continuación:

Calculadora de intereses legales

Por favor ingresar los siguientes datos:

Monto de la Deuda:

337 573,60

Moneda:

Moneda Nacional (Sol Oro, Inti, Nuevo Sol - Sol)

Fecha Inicial

07/Enero/2021

Día de Pago:

16/Enero/2025

Tasa de Interés:

Legal Efectiva

Interés Generado:

34 095,80

Monto + Interés:

371 669,40

- 6.53. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido, debiendo recalcularse los intereses legales conforme a lo descrito en el numeral que antecede.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital Constitución la devolución y/o pago a favor del demandante de la suma de S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Clausula Séptima del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

6.54. Señala que la Garantía de Fiel Cumplimiento se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, luego de lo cual corresponde que dicha garantía sea restituida a su otorgante.

6.55. Señala también que, habiéndose originado la obligación de la ENTIDAD de emitir la Conformidad de Prestación del Servicio, esto a su vez origina la obligación de la ENTIDAD de devolver al CONTRATISTA la garantía otorgada para la firma del contrato y que para su caso está constituida por el 10% de retención del valor del contrato

Resumen de la posición de la DEMANDADA

6.56. Señala que la pretensión se determinará y efectuará en el laudo.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

6.57. En el marco de la pretensión materia de análisis, respecto a la vigencia de la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por el CONSORCIO para la suscripción del contrato, el numeral 126.1 del Artículo 126° del RLCE dice:

"... 126.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

6.58. Así también, la Opinión N° 090-2021/DTN señala:

*"... Como se aprecia, la garantía de fiel cumplimiento constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato; así, el postor ganador debe entregarla a la Entidad por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, siendo que **dicha garantía debe mantenerse vigente durante todo el período de la ejecución contractual, hasta la conformidad de la recepción de la prestación contratada (cuando el objeto sea la entrega de bienes o la prestación de servicios en general y consultorías en general, respectivamente).***

De esta manera, se advierte que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, y no sólo garantizar el cumplimiento de alguna o algunas prestaciones que comprenda dicho contrato.

Por lo tanto, si una contratación de servicios –distintos a los de consultoría de obra– involucrara una serie de prestaciones a cargo del contratista, este debe respaldar el cumplimiento del total de sus obligaciones contractuales a través de una garantía de fiel cumplimiento, la cual debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la cabal ejecución del total de las prestaciones a su cargo, por un monto equivalente al 10% del contrato; en esa medida, dicho monto respalda un eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista y el perjuicio ocasionado por este, independientemente del porcentaje de ejecución de tales prestaciones...” (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

Para el presente caso, este Tribunal Arbitral ha determinado la validez y vigencia del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito para la Ejecución del servicio “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V, DISTRITO CONSTITUCIÓN – OXAPAMPA – PASCO”; consecuentemente, los efectos contractuales para las PARTES se tienen por restituidos y reconocidos; también se ha determinado que la Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM constituye la recepción y conformidad del Expediente Técnico del proyecto, tras haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las prestaciones a cargo del CONTRATISTA; en tal sentido, para la suscrita Arbitro Único ha quedado plenamente demostrado que la obligación de mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento ha desaparecido, correspondiendo que se le restituya y/o devuelva al CONSORCIO la referida garantía por el monto contenido en ella.

6.60. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no que el árbitro único ORDENE a la demandada que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

Resumen de la posición del DEMANDANTE

6.61. Señala que, dado que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá dichos pagos, corresponde que se imponga el pago de las costas y costos del proceso hacia la demandada ya que durante todo el proceso arbitral se ha mostrado renuente en asumir

la parte de los costos que le corresponden, siendo que al final el demandante quien ha asumido el pago de la totalidad de ello.

- 6.62. Señala también que el presente arbitraje se originó a raíz del actuar arbitrario de la demandada, lo que implica que haya tenido que recurrir a la vía arbitral, tanto más, si el Art. 166 del RLCE señala que: "si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados".

Resumen de la posición de la DEMANDADA

- 6.63. Señala que esta pretensión se determinara luego de tramitarse las etapas que preceden a la emisión del laudo que corresponda.

Posición definitiva del ARBITRO ÚNICO

- 6.64. Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que la MUNICIPALIDAD asuma los costos generados por el presente arbitraje.

- 6.65. Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, **no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje**, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, el REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.

- 6.66. Los numerales 52 y 53 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

"... 52. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

53. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.67. Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

*"... Distribución de los costos arbitrales
Artículo 103°.-*

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

Finalmente, el numeral 1 del artículo 73° de la LEY DE ARBITRAJE señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.
3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..." (La negrita, cursiva y subrayado son nuestros)

- 6.69. Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta –en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: "el que pierde paga" (Teoría del Vencimiento).
- 6.70. Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta, pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso en esta caso arbitro, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.
- 6.71. Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena

respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

6.72. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado cinco pretensiones principales, incluyendo la presente, evidenciándose que ambas PARTES han formulado sus respectivos medios de defensa, así como también ambas PARTES han efectuado el pago de la parte que les correspondía, es decir, han cumplido con la forma de pago establecida en el Acta de Instalación.

6.73. Atendiendo a ello y en aplicación de los artículos 52° y 53° del Acta de Instalación, artículo 103° del REGLAMENTO y de los artículos 70° y 73° de la LEY DE ARBITRAJE, el Tribunal Arbitral dispone que los costos del presente arbitraje sean asumidos en partes iguales, tal como consta en autos, razón por la cual no corresponde imputar sobre una de ellas el pago por tal concepto.

6.74. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **INFUNDADO** en su totalidad el presente punto controvertido.

7. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, la Árbitro Único, en Derecho, **LAUDA:**

7.1. **PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE DECLARA NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Resolución de Alcaldía N° 342-2023-MDC/A su fecha 04 de diciembre de 2023 y la Carta N° 090-2023-MDC/ALC, mediante las cuales la Municipalidad Distrital Constitución declara la nulidad de oficio del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, por vulnerar las normas y el orden público.

7.2. **SEGUNDO. - DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital Constitución la entrega a favor del Consorcio GD Group Saneamiento del **Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio**, conforme a la cláusula novena del contrato; **DECLARANDO y RECONOCIENDO** que el contratista ha cumplido con ejecutar al 100% la prestación y/u obligaciones a su cargo contenidas en el Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC y la Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM mediante la que se aprueba la modificación de las Características Técnicas y/o Condiciones Originales (Prestaciones Adicionales) del proyecto, cuyo Expediente Técnico fuera aprobado mediante Resolución Gerencial N° 206-2020-MDC/GM de fecha 22 de diciembre de 2020, **EXIMIENDO** al contratista de cualquier otra responsabilidad no prevista en los documentos antes indicados.

- 7.3. **TERCERO. - DECLARAR FUNDADA** la segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital Constitución que realice **EL PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de la suma de **S/ 337,573.60 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 SOLES)** correspondiente al último pago (sexto entregable) del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC, modificado con Resolución Gerencial N° 0113-2020-MDC/GM; así como también **SE LE ORDENA** el pago de los **INTERESES LEGALES** generados por la suma de **S/ 34,095.80 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES)**.
- 7.4. **CUARTO. - DECLARAR FUNDADA** la tercera pretensión accesoria a la primera pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Distrital Constitución la **DEVOLUCIÓN Y/O PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de la suma de **S/ 196,574.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)**, entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Clausula Séptima del Contrato de Servicio de Consultoría N° 048-2018-GM-MDC.
- 7.5. **QUINTO. - DECLARAR INFUNDADA** la segunda pretensión principal de la demanda arbitral, en consecuencia, **SE DISPONE** que los costos arbitrales deberán ser asumidos por ambas partes de forma equitativa.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas, sin perjuicio de registrarlo en el Portal del SEACE de acuerdo a la ley de la materia. –

Firmado:


Abog. Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
Arbitro Único


Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur
Secretaría Arbitral